

RECURSO CÍVEL Nº 5005576-68.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO AQUINO DOS SANTOS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS E AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO INSS À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para o fim de afastar a condenação do INSS à reparação dos danos materiais reconhecidos na sentença. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

5005576-68.2024.4.02.5006

500003544931 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5005576-68.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO AQUINO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação que versa sobre descontos não autorizados a título de contribuição associativa.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"(...)

Fundamento e decido.

Da ilegitimidade passiva do INSS e incompetência da Justiça Federal

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva ad causam do INSS, tenho que a mesma não merece prosperar, pois a mesma é responsável, como conveniente, pelos descontos, na medida em que deve zelar, em atenção ao princípio da eficiência, para que fraudes não ocorram, ou seja, é responsável por fiscalizar a regularidade do cadastramento das entidades junto ao seu sistema e das consignações realizadas.

Logo, a Justiça Federal é competente para julgar a presente ação.

Da ausência de interesse de agir

O fato de o réu ter contestado o pedido no evento 10, PET2, bem demonstra o interesse jurídico da parte autora. Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.

Da impugnação ao valor da causa

Não merece prosperar a alegação da correção acerca da impugnação ao valor da causa, eis que o valor apontado na inicial corresponde ao valor de indenização de danos morais e materiais, bem como o valor descontado do autor a título de CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069.

Do Mérito

Alega a parte autora, em suma, que é beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária pelo INSS e que verificou descontos indevidos em seu benefício, referente a contribuição associativa - CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069 desde dezembro de 2023, que alega desconhecer.

Não se pode olvidar que, ao caso, se aplica a responsabilidade objetiva, decorrente do exercício pelas rés de atividade de risco, na forma como estabelecida no parágrafo único do artigo 927 do CC/02, porquanto se procede a pagamento de benefícios previdenciários, consentindo com recolhimentos de contribuições associativas.

No tocante ao INSS, aplica-se ainda, em primeiro lugar, o regime da responsabilidade civil objetiva em função da teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).

Justamente por isto, não há como afastar o dever de máxima diligência decorrente desta atividade.

Assim, especificamente em relação ao INSS, como agente pagador, é seu dever diligenciar para que não ocorram fraudes, ou, ao menos, agir de molde a inibir a sua incidência, em atenção ao princípio constitucional da eficiência que rege a Administração Pública, o que não foi o caso dos autos, uma vez que não foi apresentada em sua peça de defesa nenhuma prova de que assim procedeu.

O dispositivo legal supracitado refere-se à cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, fundamentada pelo risco da atividade desempenhada.

O Princípio da solidariedade social fundamenta o dever indenizatório no caso de ocorrência de dano injusto, mesmo quando se tratar de atividade lícita; já que o ilícito não é de modo absoluto essencial à imposição da responsabilidade civil objetiva.

Ao realizar descontos em vencimentos ou proventos que não foram subscritos pelos segurados, incorre a autarquia ré em gravíssima mácula ao dever de vigilância, segurança e diligência a ela perfeitamente imputáveis.

Ressalte-se, mais uma vez, que não foi produzida nenhuma prova, nem apresentado qualquer indício de ter agido com observância a tais deveres. Pelo contrário, limitou-se a alegar que apenas procedia os descontos que lhe foram noticiados, sem, ao menos, solicitar da instituição o respectivo instrumento assinado pelo segurado.

Por sua vez, a segunda ré contestou a presente ação, apresentando contrato de filiação associativa assinado eletronicamente pela parte ré (evento 10, CONTR5), e alegando que procedeu com a exclusão do associado, com a devolução dos valores descontados, com a juntada de documento que comprova a exclusão e a determinação de reembolso dos valores descontados entre dez/2023 e 08/2024, com o compromisso de não proceder com novos descontos futuros (evento 10, CARTA4).

Contudo, no que tange à assinatura digital aposta no documento apresentado pela ré no evento 10, CONTR5, não há comprovação se de fato foi o autor que efetuou a assinatura, pois não traz a validação da assinatura eletrônica da parte autora.

Sendo assim, a AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS não se desincumbiu do ônus da prova (art. 14, §3º, II, do CDC e art. 373, II, do CPC), não tendo apresentado qualquer prova de que a filiação à associação foi efetivamente contratada pela parte autora. Tal diligência constitui ônus processual da parte requerida, de forma que, não sendo por ela observada, operar-se-á a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora em sua peça inicial, nos termos do artigo 400 do CPC.

Neste sentido, não se pode olvidar que é de conhecimento geral os inúmeros casos desta natureza, e em razão disto, já se deveria ter adotado medidas inibitórias à ocorrência de fraudes como esta, o que não ocorreu.

Sendo assim, devem cessar os descontos que vem sendo efetuados e, além disso, uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, exsurge o dever de reparar o dano sofrido, material e moral.

Sobreleva registrar que não há informações claras nos autos sobre se os descontos já foram cessados ou por quanto tempo teve a autora que suportá-los, o que obviamente influi na apuração da extensão do dano ocorrido.

Não obstante, o dano material se consubstancia nos valores que foram descontados dos proventos da autora referentes a essas mensalidades associativas, a ser efetivamente apurado na fase executiva do procedimento.

Cabe analisar o pedido de repetição do indébito, previsto no art. 42 do CDC. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer, em seu art. 42, p. ú, que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Trata-se, justamente, da hipótese dos autos, pois houve o desconto de valores indevidos no benefício da parte autora, referentes a contribuição associativa firmada sem sua autorização.

Ademais, sendo o "engano justificável" fato impeditivo do direito do autor, cabia à associação ré a sua prova (art. 373, II, NCPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta seara, colaciono o entendimento exarado no EAREsp 1.501.756-SC pelo Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/02/2024.

"(...) A Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021, fixando a seguinte tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Dessa forma, a regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. No caso em análise, contudo, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ, qual seja, o fato de o referido precedente ter modulado os efeitos da aplicação de sua tese, ficando estabelecido que, não obstante a regra geral, o entendimento fixado se aplica aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão em 30.3.2021."

Considerando que a parte autora comprovou que os descontos se iniciaram em 12/2023, aplica-se o referido precedente (evento 1, HISCRE9).

Dessa forma, julgo procedente o pleito de repetição do indébito.

Em relação ao dano moral, considerando a natureza alimentar da verba de que a parte autora ficou privada, em razão de falha na conduta da associação, impõe-se a esta o dever de arcar com a compensação por dano moral.

De fato, a subtração inadvertida de parte de rendimento de natureza alimentar não constitui mero dissabor cuja tolerância seja exigível. Cuida-se de fato causador de abalo moral injusto, merecedor de reparação.

Na hipótese, o dano moral ocorre in re ipsa, devendo ser reconhecido, em razão de uma presunção oriunda da experiência normal. Afinal, nenhuma pessoa deixa de se sentir abalada, sendo privada injusta e inadvertidamente, de parcela da verba destinada a seu sustento e o de sua família. Nesse contexto, o que se presume não é o fato deflagrador do dano extrapatrimonial (este suficientemente comprovado nos autos), mas a aptidão deste fato para deflagrar as lesões de ordem moral.

Mas a indenização por dano moral não é fonte de enriquecimento. O valor da reparação deve ser estimada de modo prudente, com a necessária sensibilidade para a extensão do dano causado e a gravidade da ação culposa, atentando-se, em especial, para a finalidade voltada a dissuadir o causador do dano a não repetir o ato que o provocou.

No entanto, também deve ser considerado o diminuto valor dos descontos e o curto período alegado na inicial.

Nessa linha de raciocínio, merecem compensação os danos causados ao patrimônio moral da parte autora, sendo que arbitro a indenização em R\$ 3.000,00 (três mil reais), valor razoável e proporcional, suficiente para compensar a vítima pelo dano causado e desestimular a reincidência em condutas desta natureza.

Registre-se que a responsabilidade do INSS, no presente caso, é subsidiária, isto é, somente poderá ser executado o título judicial (após o trânsito em julgado) em face da autarquia caso frustrada a execução em face da associação corré.

Da Tutela provisória

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência da segurada. Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência, para que o INSS cesse o desconto mensal.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

I - Determinar que o INSS proceda à imediata suspensão dos descontos, que estavam sendo realizados nos proventos da parte autora, a título de CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069;

II - Condenar a AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, a devolver todos os valores que foram indevidamente descontados dos proventos da parte autora, bem como a pagar, a título de compensação por dano moral, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

III - Condenar a AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS a restituir, em dobro, os valores descontados mensalmente, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto, também conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV - Reconhecer a responsabilidade subsidiária do INSS pelo pagamento dos valores da condenação.

CONCEDO a tutela provisória de urgência, devendo ser intimada a CEABDJ para que cesse, em definitivo, o desconto mensal com comprovação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento.

O valor da condenação deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9099/95 c/c 1º da Lei 10.259/2001).

Apresentados Embargos de Declaração e, havendo efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em seguida, voltem os autos conclusos.

Havendo interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95 c/c 219 do NCPC).

Após, encaminhem-se os presentes autos para a Turma Recursal, sendo desnecessário o juízo de admissibilidade nesta instância, nos termos dos Enunciados nº 34 do FONAJEF e nº 79 do FOREJEF da 2ª Região, bem como da Resolução STJ/GP nº 1/2016.

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

P.I."

Recorre o INSS aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência da Justiça Federal após sua exclusão da lide. Suscita a prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argui a inexistência de ato ilícito e de vantagem financeira da autarquia; a inexistência de nexo causal; e a culpa exclusiva de terceiro. Reafirma que as quantias descontadas em folha de pagamento foram integralmente repassadas à associação, única responsável pela restituição e pela indenização dos danos morais. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a natureza subsidiária da responsabilidade da autarquia.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** – Tema 326). Todavia, não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática, nas instâncias ordinárias. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

No mais, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuar-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição há reconhecer no caso concreto.

No mérito, reputo necessário estabelecer algumas premissas anteriormente a análise das demais alegações recursais:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é restrita ao âmbito das relações de consumo, em que se visualiza a existência das figuras do consumidor (artigo 2º do CDC) e do fornecedor de produtos ou serviços (artigo 3º do CDC).

Ocorre que o INSS é uma autarquia e, como tal, desempenha atividade típica de Estado, a ele se aplicando o mesmo regime imposto à Fazenda Pública, atuando sem qualquer interesse econômico ou comercial, buscando, apenas, a consecução do interesse coletivo.

Desse modo, sendo a relação do segurado com o INSS uma relação previdenciária e de caráter público, não haveria mesmo falar em aplicação do CDC a este caso concreto.

Além disso, destaco que, a despeito das divergências, entendo que nem mesmo às associações, em hipóteses como a vertente, se aplica o CDC.

Ora, as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, nos termos do que dispõe o artigo 53 do CC. Logo, o associado integra a associação, detendo, inclusive, direito de voto, sendo certo que esta não desenvolve atividade empresarial lucrativa, razão pela qual não se enquadrariam as funções de associação e associado nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados no CDC.

É certo que, no caso dos autos, o autor não é associado, sendo esta justamente a questão discutida na lide. Ocorre que, ainda assim, não haveria propriamente uma relação de consumo, mas sim uma relação privada, em que o suposto causador de danos deve responder pelos prejuízos e danos causados à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

"(...) o o Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..."REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)

Como esclarecido acima, não há que se falar em aplicação do CDC à lide e, da mesma forma, não há como se reconhecer a solidariedade por eventual reparação de danos entre o INSS e a associação, vez que não há relação de consumo (artigo 7º, parágrafo único, do CDC).

Contudo, tampouco haveria que se falar em solidariedade por qualquer outro fundamento. Nos termos do artigo 264 do Código Civil, *"há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda"*.

Ocorre que as relações do segurado com o INSS e do pseudoassociado com a associação são distintas e, portanto, também geram obrigações distintas e independentes. Isso a começar porque diante da prática de atos ilícitos, respondem a autarquia e associação por fundamento normativo diverso.

Além disso, há que se ressaltar que a entidade pública demandada não pode responder pelos valores indevidamente descontados pela associação a título de danos materiais, vez que destes não se beneficia, o que repugna ainda mais a aplicação da solidariedade.

Nesse particular, resalto que a condenação do INSS no pagamento de danos materiais, ainda que subsidiária, apenas geraria o locupletamento da associação ré, que embora tenha se beneficiado da totalidade de valores, apenas poderá sofrer regresso da autarquia pela metade do valor.

No caso dos autos, o autor sofreu descontos não autorizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição associativa em favor da AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. Diante desse contexto é que a sentença aplicou ao caso condenou o INSS, em caráter subsidiário, à reparação dos danos materiais e morais sofridos pela parte autora.

Todavia, entendo que os **danos materiais** devem ser suportados apenas pela associação ré, vez que o desconto realizado apenas a esta beneficia. Sendo assim, **afasto** a condenação subsidiária do INSS à reparação dos danos materiais sofridos pela parte autora.

No que tange à condenação da autarquia em **danos morais**, decerto restou configurada a sua omissão ao não ser vigilante quanto aos descontos não obrigatórios realizados mediante fraude, razão por que cabível sua condenação subsidiária ao pagamento de danos morais, que **mantenho**.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para o fim de afastar a condenação do INSS à reparação dos danos materiais reconhecidos na sentença. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

